

1529809-24.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PETER ECKSCHMIEDT

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 10ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Nesse sentido:

"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

10ª Vara Criminal

Avenida Abrão Ribeiro 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1529809-24.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529809-24.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2336901/2021 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS, 21890363 - 101º

D.P. JDIM IMBUIAS, 2336901 - 101º D.P. JDIM IMBUIAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEWIN RODRIGUES DO PRADO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PETER ECKSCHMIEDT

Vistos.

JONATHAN CARVALHO DANTAS e KEWIN RODRIGUES DO PRADO, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas regras do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque no dia 10 de dezembro de 2021, por voltadas 06h30min, na Rua Balneário São José, 1140 - Balneário São José, nesta Capital, agindo em concurso e com unidade de desígnios, traziam com eles, para a entrega a consumo de terceiros, 31 porções de crack, com peso líquido de 5,1g; 03 porções de ecstasy, com peso líquido de 0,52g; 69 porções de maconha, com o peso líquido de 171,6g; 56 porções de cocaína, com o peso líquido de 34,8g; 01 frasco de lança-perfume, com a quantia líquida de 10ml; substâncias entorpecentes e que determinam dependência física ou

psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, os policiais militares realizavam patrulhamento no local, conhecido por venda de drogas, quando avistaram os réus, os quais, ao verem os policiais, tentaram correr para direção opostas; contudo foram detidos. Realizada busca pessoal, na mochila de JHONATAN, foram localizados os entorpecentes e, em poder de KEWIN, foi encontrada uma quantia de R\$ 208,00 e papéis com anotações típicas de contabilidade do comércio de entorpecente. O acusado JHONATAN confessou o delito, ao passo que KEWIN negou a autoria delitiva.

O procedimento especial foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida (fls. 112/115), os réus foram citados (fls. 134/139) e apresentaram resposta à acusação (fls. 143/147). Em audiência realizada em 03 de fevereiro de 2022 foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e foi concedida a liberdade provisória aos réus (fls. 148/149). Posteriormente, em audiência realizada em 10/02/2022, foi realizado o interrogatório dos réus (fls. 170/178).

Laudo pericial a fls. 162/165.

O Ministério Público, em debates, requereu a condenação dos réus nos exatos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa, em debates, clamou pela absolvição dos réus.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A denúncia PROCEDE EM PARTE.

1) DA MATERIALIDADE.

A materialidade do crime restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04 e 11/13), Boletim de Ocorrência (fls. 07/10), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 15/16), Laudo de Constatação (fls. 18/22), Exame químico-toxicológico (fls. 162/165) e pela prova oral colhida em juízo.

2) DA AUTORIA.

Interrogado na delegacia (fls. 31), o réu JHONATAN confessou a traficância no local dos fatos, informando ainda que o acusado KEWIN é usuário e que tinha acabado de vender a ele 02 pinos de cocaína. Ainda, disse que, ao ser detido, os entorpecentes estavam no chão e não em sua posse. Para mais, relatou que, ao ouvir a voz de abordagem, tentou fugir e veio ao solo, permanecendo imóvel devido ao disparo de arma de fogo efetuado pelos policiais. Por fim, disse ter agido por necessidade, em decorrência do desemprego, sendo a data da prisão o terceiro dia que estava traficando. Que vendia maconha, cocaína, crack, ecstasy.

Em juízo, o réu JHONATAN alegou que trabalha como vendedor na loja da sua mãe, que fica próxima ao local. Que é usuário de maconha. Negou as acusações. Que estava passando no local para abrir a loja de sua mãe e a polícia apareceu efetuando tiro. Que correu e foi abordado e preso pela polícia. Que a sacola apreendida estava no chão e não com ele. Que confessou na delegacia por receio dos policiais militares, que fizeram ameaças. Que não conhecia os policiais militares que efetuaram a sua prisão.

Na delegacia (fls. 35), o acusado KEWIN negou a prática delitiva. Informou que é usuário de maconha e cocaína e que morava próximo ao local e que, quando os

policiais deram voz de prisão, mostrou a eles dois pinos de cocaína e R\$ 30,00 que tinha consigo. Ainda, informou que os policiais inseriram os referidos pinos e a quantia em dinheiro na mochila do traficante e encaminharam os dois para a delegacia. O acusado não tem passagens.

Em juízo, o réu KEWIN alegou que é usuário de maconha e cocaína há dois anos, mas que ora não usa mais. Que na data dos fatos estava no local, que é próximo à sua residência, para comprar entorpecente e foi abordado pela polícia que o prendeu por tráfico. Que o corréu Jhonatan também foi enquadrado e preso na mesma oportunidade. Que no dia estava no local dos fatos aguardando o fornecimento da droga pelo traficante quando foi abordado pela polícia. Que estava com apenas R\$ 50,00 no bolso, que o policial pegou e jogou dentro da sacola que foi apreendida com o corréu Jhonatan. Não presenciou a prisão de Jhonatan.

Ouvido sob o crivo do contraditório, o policial militar ANDERSON AZEVEDO, disse, em juízo, que estava em patrulhamento de rotina com seu colega de farda WASHINGTON quando, no local dos fatos, que é conhecido como ponto de tráfico, avistou dois indivíduos em atitude suspeita, os quais se evadiram quando avistaram os policiais. Ato contínuo, abordou um dos indivíduos que estava portando uma mochila com os entorpecentes apreendidos e o seu parceiro abordou o outro indivíduo que estava com dinheiro e anotações no bolso da calça, sendo que ambos alegaram que eram usuários. Não conhecia os réus.

Por sua vez, o policial militar, WASHINGTON ELAINO FERREIRA GOMES, disse, em juízo, que estava em patrulhamento de rotina com seu colega de farda ANDERSON quando, no local dos fatos, que é conhecido como ponto de tráfico, avistou dois indivíduos em atitude suspeita. Ato contínuo, abordou um dos indivíduos que estava com dinheiro e o seu parceiro abordou o outro indivíduo que estava com os entorpecentes apreendidos, sendo que ambos admitiram o envolvimento com a traficância. Não se recorda se houve apreensão de caderno. Não conhecia os réus.

2.1) DA AUTORIA (CORRÉU KEWIN).

Em relação ao corréu KEWIN, tenho que a acusação não logrou comprovar, estreme de dúvida, os fatos descritos na denúncia. Vejamos.

Segundo relatos dos policiais, não foi encontrado nenhuma substância ilícita com o réu Kewin, apenas dinheiro e anotações referentes ao tráfico de entorpecentes. Todavia, embora conste no auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 que houve a apreensão de duas folhas de papel com anotações, nada há nos autos acerca de referida prova.

Há ainda a palavra do corréu Jhonatan na seara policial afirmando que Kewin era usuário.

Logo, não há provas de que o corréu Kewin traficava drogas no local. O fato de ele ter sido flagrado no palco dos fatos, por si só, não comprova a sua autoria e mercância no tráfico.

O corréu KEWIN, primário e sem antecedentes criminais (fls. 47/49), desde a sua prisão sempre alegou que era usuário. Dos autos, nada emergiu que pudesse macular a sua alegação de usuário.

Diante desse quadro, não comprovados os fatos descritos na denúncia, de rigor a sua ABSOLVIÇÃO por falta de provas.

2.2) DA AUTORIA (CORRÉU JHONATAN).

Restou comprovada a autoria com relação ao corréu Jhonatan.

Inicialmente, consigno que ele confessou o delito em solo policial e, embora tenha mudado a versão dos fatos em juízo, a sua nova narrativa restou isolada diante das provas dos autos.

Os depoimentos das testemunhas, policiais militares, são válidos e eficazes para a convicção condenatória em relação ao corréu Jhonatan, até por não haver dúvidas sobre sua lisura, estando em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem outra prova contrária ao coeso contexto probatório. Neste sentido entende o STJ:

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)." (AgRg no AREsp1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

Ademais, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais, e, no caso dos autos, a versão do réu Jhonatan restou completamente isolada, nada apresentando de concreto capaz de ilidir as declarações dos milicianos, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo, conduta perpetrada pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

Nesse sentido:

"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza e diversidade de drogas (crack, cocaína e maconha) em poder do réu, o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido pelos policiais), bem como a falta de comprovação pelo réu de exercício de atividade laboral formal ou informal lícita, são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercância, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Ressalta-se que a conduta do acusado foi corroborada pelas provas carreadas nos autos.

Já a versão do réu, ao revés, não se sustenta. Ele foi avistado pelos policiais e empreendeu fuga. Ainda, em juízo, confessou que havia uma mochila com drogas, mas que não era dele. Ora, a sua versão não se sustenta, até porque, conforme relato dos policiais, não havia outras pessoas no local onde foi efetuada a prisão do réu

Jhonatan. Quer dizer, para dar crédito à versão do acusado, teríamos que considerar o absurdo: dois policiais militares, no exercício do seu mister, carregando consigo uma mochila carregada de substâncias entorpecentes apenas com o fito de forjar flagrante em detrimento de transeuntes. Portanto, cristalino que a versão do réu Jhonatan não é digna de crédito.

Em suma, a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas em relação ao corréu JHONATAN. No mais, não existem causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

Assim, a condenação, em face de JHONATAN, é medida que se impõe.

DOSIMETRIA:

O crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, apresenta pena abstrato de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1500 (mil e quinhentos) dias multa.

1ª FASE DA DOSIMETRIA PENAL. O art. 42 da Lei 11.343/06 estabelece, como circunstâncias preponderantes no contexto da análise da primeira fase da dosimetria, a ponderação da natureza e quantidade de drogas.

No caso dos autos, de se ressaltar a quantidade razoável de droga que foi apreendida com o réu. Além disso, é cediço as consequências sociais perniciosas do tráfico de drogas, destacando-se a natureza, a diversidade e a letalidade das várias espécies de drogas apreendidas, de grande poder destrutivo e alto índice viciante, geradora de invencíveis problemas na saúde pública.

Diante desse quadro, fixo a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, o que representa sanção de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

2ª FASE DA DOSIMETRIA PENAL. Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

3ª FASE DA DOSIMETRIA PENAL.

Em razão do disposto no artigo 33, § 4º da Lei Antitóxicos, sendo o réu primário, com bons antecedentes e não havendo provas nos autos de que se dedique às atividades criminosas com habitualidade e íntegra organização criminosa, reduzo a pena em 1/3.

Assim, fixo a pena definitiva do réu em 03 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão, mais o pagamento de 389 dias-multa no piso unitário legal.

VALOR DA MULTA.

O valor do dia multa será calculado no valor unitário mínimo (art. 43 da Lei nº 11.343/2006), haja vista a inexistência de provas a respeito de riqueza, e deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, desde a data da infração (TACrSP, RT 628/338).

REGIME PRISIONAL.

Tendo em vista que a redação dada ao artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 pela Lei nº 11.464/07 estabelecendo a obrigatoriedade de cumprimento inicial fechado nos casos de condenação pelo delito do artigo 33 da Lei Antidrogas foi declarada, por maioria de votos e de forma incidental, inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC 111.840, da Relatoria do Exmo. Sr. Ministro Dias Toffoli, ocorrido em 27/06/2012, e, ainda em atenção ao que restou

decidido no HABEAS CORPUS Nº 596.603/SP do Colendo STJ, a pena do crime de tráfico terá regime inicial aberto.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA.

Tendo o delito sido perpetrado sem violência ou grave ameaça, e, considerando que a pena fixada não supera 04 (quatro) anos, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, motivo pelo qual substituo a pena corporal do réu por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo prazo da pena carcerária aplicada, a ser indicada na fase de execução.

Nesse sentido:

"PENA - TRÁFICO DE DROGAS - SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS - INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006. A vedação à substituição da reprimenda privativa de liberdade pela restritiva de direitos, prevista na Lei de Tóxicos, foi declarada inconstitucional, ante o princípio da individualização da pena - habeas corpus nº 97.256, relator o ministro Carlos Ayres Britto, julgado em 1º de setembro de 2010 pelo Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 16 de dezembro imediato. PENA - EXECUÇÃO - REGIME DE CUMPRIMENTO. Não se tratando de réu reincidente, ficando a reprimenda no patamar de 4 anos e sendo as circunstâncias judiciais positivas, cumpre observar o regime aberto e apreciar a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - artigos 33 e 44 do Código Penal" (STF, HC 125.188/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 04/10/2016).

"Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Condenação. 3. Decisão do STJ que se limitou a determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem sem adentrar o mérito. Supressão de instância. Superação. 4. Regime inicial fechado. Deficiência de fundamentação. Constrangimento ilegal configurado. 5. A jurisprudência do STF consolidou entendimento de que a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto. 6. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos dispostos no art. 44 do CP. 7. Ordem concedida de ofício para fixar o regime aberto de início do cumprimento da pena e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo juízo das execuções criminais" (STF, HC 133.617/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 10/05/2016).

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para o fim de:

A) ABSOLVER o réu KEWIN RODRIGUES DO PRADO de toda a acusação formulada, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

B) CONDENAR o réu JONATHAN CARVALHO DANTAS como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 03 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 389 dias-multa no piso unitário legal.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito

consistentes em prestação de serviços à comunidade.
Os réus poderão recorrer em liberdade desta sentença.

Custas pelos réus, na forma da Lei Estadual nº 11.608/2003, observada a gratuidade que defiro neste ato em razão da defesa patrocinada pela DEFENSORIA PÚBLICA

Nos termos do art. 50-A da Lei 11.343/2006, DETERMINO a incineração das drogas apreendidas, sendo tomadas as devidas cautelas legais.

Determino o perdimento, em favor da União, dos valores apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para o cumprimento do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-se ao Juízo competente.

P.R.I.C.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA